

1500375-43.2020.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... de arma de fogo, ainda que no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de paciente primário e de bons antecedentes, cuja dedicação às atividades criminosas - a qual justificou a negativa de incidência do tráfico privilegiado na fração máxima legal -, somente foi reconhecida, em virtude de ele possuir somente uma passagem pela Vara da Infância e da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

1ª Vara

R. Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500375-43.2020.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500375-43.2020.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia RAFAEL DOS SANTOS, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que na tarde de 4 de março de 2020, por volta de 16:30h, na Rua Maria Amaro de Oliveira, nº 45, Mato Dentro, nesta cidade e comarca de Ubatuba, Rafael dos Santos, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior da sua residência, 01 (uma) munição íntegra, calibre .380, de uso permitido, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fl. 7 e laudo pericial de fls. 43/5.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Rafael dos Santos tinha em depósito, para consumo pessoal, uma porção de maconha, com peso aproximado de 5,0 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fl. 7 e laudo toxicológico de fls. 62/4.

Segundo o apurado, Rafael - já conhecido dos meios policiais - era suspeito de ter praticado um furto contra a Igreja Ágape. Assim, guardas civis se dirigiram até a sua residência com o objetivo de localizar alguns dos objetos subtraídos. A res furtiva não foi encontrada; contudo, os agentes lograram êxito em apreender 01 (uma) munição calibre .380 intacta dentro de seu guarda-roupa. Ainda no quarto de

Rafael, os guardas encontraram sobre uma penteadeira uma porção pequena de "maconha" com peso bruto aproximado de 5,0 gramas para consumo pessoal. Denúncia recebida em 05 de outubro de 2020 (fls. 72/73). Citado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 97/99. O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada audiência de instrução e julgamento (fl. 106).

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

O réu não foi interrogado, uma vez que, intimado não compareceu à audiência.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, pediu pela absolvição do réu, com a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no menor patamar legal.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA REVELIA

Conforme se verifica da certidão de fl. 115, o denunciado foi devidamente intimado para a respectiva audiência de instrução e julgamento e não compareceu.

Neste caso, aplica-se o art. 367, do Código de Processo Penal, tendo o processo seguimento sem sua presença.

O feito encontra-se em ordem. Não há outras preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12, da lei 10.826/03.

A ação penal é IMPROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se a ausência de comprovação da materialidade delitiva.

DO DELITO DO ART. 12, DA LEI 10.826/06

A corrente doutrinária majoritária classifica o crime a partir de três elementos (teoria tripartite), quais sejam: fato típico, ilicitude e culpabilidade.

O fato típico é o fato humano que se enquadra com perfeição aos elementos descritos pelo tipo penal.

A doutrina aponta como sendo quatro os requisitos do fato típico: conduta, resultado naturalístico, relação de causalidade (nexo causal) e tipicidade.

Dentro os elementos que compõem o fato típico, se encontra a tipicidade (strictu sensu). Esta pode ser dividida em formal e material.

Tipicidade formal é o juízo de subsunção entre a conduta praticada pelo agente e a norma penal.

De seu turno, tipicidade material é a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado.

No caso dos autos, anoto que, embora comprovada a tipicidade formal da conduta (mera subsunção do fato à norma), entendo ausente a tipicidade na vertente material.

Isto porque, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fl. 07, com o denunciado foi apreendido tão somente um único cartucho de calibre .380, desacompanhado de qualquer arma de fogo capaz de efetivar o disparo de tal projétil.

Em tal caso, a situação se amolda com perfeição à aplicação do princípio da insignificância.

O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, justamente pela falta de sua vertente material.

Segundo o Des. do TJSP Carlos Vico Manãs "o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de

subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo material, de cunho valorativo, de sua efetiva lesividade ao bem jurídico penalmente tutelado". Além disso, mesmo que o denunciado seja reincidente, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, nesse caso, cabe ao juiz avaliar caso a caso.

"Importante registrar, finalmente, que a mera circunstância de ser o ora paciente reincidente não basta, por si só, para afastar o reconhecimento, na espécie, do denominado delito de bagatela" (Trecho do voto Min. Celso de Mello no julgamento do HC 155.920, julgado em 27.04.2018)

Corroborando este entendimento, segue recente julgado do E. Superior Tribunal de Justiça com aplicação do princípio da insignificância em caso análogo ao presente: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES EM CONCURSO MATERIAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ABSOLVÊ-LO DA IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ENTENDIMENTO QUE NÃO PODE LEVAR À PROTEÇÃO DEFICIENTE DO BEM JURÍDICO TUTELADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO AGENTE. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens.

- Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ.

- A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidos oito cartuchos calibre .38, desacompanhados de arma de fogo, ainda que no contexto de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto trata-se de paciente primário e de bons antecedentes, cuja dedicação às atividades criminosas - a qual justificou a negativa de incidência do tráfico privilegiado na fração máxima legal -, somente foi reconhecida, em virtude de ele possuir somente uma passagem pela Vara da Infância e da Juventude (Proc. n. 0002891-76.2014.8.26.0495), razão pela qual lhe foi aplicada uma medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, cuja execução foi julgada extinta por sentença proferida em 15/10/2015 (e-STJ, fl. 149).

- Nesses termos, entendo ser cabível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte de Justiça para o reconhecimento do princípio da insignificância, ante as particularidades do caso concreto e das condições pessoais do paciente.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 534.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

Assim sendo, de rigor a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

DO DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06

Em relação ao delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06, observa-se que não se encontra devidamente comprovada a materialidade delitiva

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve mesmo a apreensão de substâncias, em tese, classificadas como drogas ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro (fls. 07).

Por essa razão, procedeu, a autoridade policial, a confecção do laudo pericial provisório de constatação desse material, o que se fez às fls. 62/64, positivando-se, ali, prematuramente, tratar-se de maconha.

Entretanto, não se vislumbra em todo caderno processual a vinda do indispensável laudo definitivo dessas supostas drogas, abrindo-se, pois, incontornável lacuna quanto à comprovação material do crime de tráfico de drogas.

Salienta-se que, conforme diversos precedente deste E. Tribunal Bandeirante, a ausência do laudo definitivo não pode ser suprida por outros elementos e implica em inequívoca inconclusão acerca da materialidade delitiva:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Tipicidade. Materialidade. Laudo de constatação. Laudo definitivo de exame químico-toxicológico. Exame de corpo de delito. Absolvição. Não sendo apresentado nos autos laudo definitivo de exame químico-toxicológico positivando a existência material do ilícito, resta tão somente subscrever a solução absolutória. (TJSP; Apelação Criminal 0000414-93.2015.8.26.0544; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas. Admissibilidade. Ausência de provas da materialidade delitiva.

Imprescindibilidade do laudo pericial definitivo para a comprovação da materialidade delitiva. Exame de constatação provisório realizado sem que o laudo pericial definitivo tenha sido produzido. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000717-08.2014.8.26.0459; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 11/07/2019)

Corrobora este entendimento o fato de que no próprio laudo de constatação provisória, resta declarado que "Este Laudo é de caráter provisório e não confirma necessariamente o resultado da identificação que será enviado no Laudo Definitivo" (fls. 62/64), sendo de rigor, a absolvição do denunciado com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para ABSOLVER, na forma do art. 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, o acusado RAFAEL DOS SANTOS da imputação do cometimento dos crimes descritos na denúncia. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Oportunamente, elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06.

Determino, ainda, o perdimento dos demais bens apreendidos em favor da União.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I. Dispensado o registro (art. 72, §6º, NSCGJ). Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Ubatuba, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA